

1500117-60.2022.8.26.0481

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

...

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500117-60.2022.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500117-60.2022.8.26.0481 - Feito nº 2022/000300

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2035277/2022, ofereceu denúncia em face de JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado às fls. 23, dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 07/02/2022, por volta das 14h10, na Rua Alziro Baltazar, 3182, Jardim Real II, nessa cidade e Comarca, JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA estaria trazendo consigo, para entrega a consumo de terceiros, 09 porções de "crack", pesando aproximadamente 1,3 grama, além de uma porção de Cannabis sativa L., drogas capazes de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar.

Realizada audiência de custódia, após a entrevista do autuado e manifestação do ilustre representante do Ministério Público e da nobre Defesa, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva na data de 08/02/2022 (fls. 46-55).

Impetrado Habeas Corpus com pedido liminar ao E. TJSP, a cautela alvitada foi indeferida (fls. 97-99).

Notificado (fls. 124), o acusado ofertou defesa prévia, ocasião em que pugnou pela revogação da prisão preventiva (fls. 106-114).

Manifestação Ministerial pelo recebimento da exordial acusatória e indeferimento do

pleito de revogação da prisão preventiva (fls. 127-130).

A denúncia foi recebida em 09/03/2022, ocasião em que foi rejeitada a hipótese de absolvição sumária e revogada a prisão preventiva de João Victor Santos de Oliveira (fls. 134-139).

O Alvará de Soltura foi devidamente cumprido em 09/03/2022 (fls. 148-150).

Deu-se por prejudicada a determinação de expedição de Alvará de Soltura em decisão liminar exarada pelo E. STJ no HC nº 726362/SP (fls. 160-164).

Requerimento de concessão de justiça gratuita ao acusado (fls. 171)

Laudos de exame químico de entorpecente e do aparelho celular apreendido acostados (fls. 196-198, 199-201 e 214-226).

O réu foi regularmente citado (fls. 228) prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado (fls. 229-233).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público pugnou pela complementação da perícia realizada no aparelho celular apreendido, o que foi deferido por este juízo.

Laudo pericial complementar do aparelho celular encartado às fls. 258-273.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva (fls. 283-285).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, por benefícios no tocante à pena (fls. 290-298).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 01-04), boletim de ocorrência (fls. 13-18), auto de exibição e apreensão (fls. 19-20), auto de constatação da natureza tóxica (fls. 21), laudos periciais químicos de entorpecente (fls. 196-198 e 199-201), que atestaram que as substâncias detectadas se tratavam de cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), que são de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado João Victor Santos De Oliveira.

Inquirida, a testemunha Neumir Cesar da Cunha Carminatti, policial militar, relatou que "Sim, nós tínhamos informações (vários usuários já havia vinte dias formalizavam essas denúncias aos policiais militares) de que João Victor traficava em Epitácio, com o seguinte modus operandi: disque entrega através de uma moto vermelha. A pessoa ligava para ele e ele ia levar as drogas. Em patrulhamento, encontramos a motocicleta vermelha cruzando a Avenida Presidente Vargas. Ao nos avistar enquanto fazíamos um breve patrulhamento, já um pouquinho mais a frente, ele empreendeu fuga em alta velocidade até que o vimos na Rua Venturosa Arcádia da Rocha, uma rua subida, com estrada de terra - e ele abriu a mão esquerda e dispensou alguma coisa ao solo. Depois de mais perseguição, ele foi abordado já na Rua Alziro Baltazar: em busca pessoal foram encontrados um celular, uma porção de maconha em sua pochete (que ele dizia ser para uso); R\$ 300,00 em dinheiro (que ele não soube explicar a procedência). Voltamos com ele até a Rua Venturosa Arcádia da Rocha e encontramos o pacote que tinha sido dispensado ao solo por João Victor: era um invólucro de cor branca com nove porções de crack prontas para venda. Foi o delegado, estávamos ele, o escrivão e eu. Acredito que o advogado não acompanhou minha oitiva na delegacia. Nada foi formalizado a respeito das denúncias anônimas dos usuários. Ah, isso o senhor tem que perguntar para ele, não para mim. Acredito eu que ele iria fazer uma entrega da maconha e não conseguiu tirá-la da pochete. Sim, devido a vários carros, motos e transeuntes que estavam pela via. Não, senhor, não fomos até a casa dele: tem que pedir mandado judicial, ele não autorizou nossa entrada em sua casa (se ele autorizasse, eu iria) e foi encontrado na via".

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Gustavo Cesar Leite, o

qual apenas complementou que "A gente tinha informações de que João Victor traficaria pela via usando uma Titan vermelha, moto. Com base nisso, efetuamos policiamento direcionado quando visualizamos o veículo na Presidente Vargas. Ao avistar a viatura, ele empreendeu fuga, realizamos patrulhamento por várias ruas da cidade, ele dispensou um objeto ao solo na Venturosa Arcádia da Rocha. Posteriormente, ele seguiu em fuga e foi abordado na Alziro Baltazar. Em busca pessoal, encontramos em sua pochete uma porção de maconha (que ele dizia ser para uso), um celular e R\$ 300,00 em dinheiro. Voltamos, então, ao local em que ele havia dispensado algo ao solo e encontramos nove porções de crack. Conduzimos o abordado à delegacia de polícia. Só estávamos na sala eu e o delegado; somente o delegado me fez perguntas lá, ninguém mais. Foi perguntado para ele, que nos disse que não autorizaria nossa ida até sua casa, onde não teria nada e nós tínhamos informações de que ele traficaria pela via e não em sua casa. Tínhamos as denúncias a respeito dele fazia, mais ou menos, cerca de 20 a 30 dias: através de abordagem a usuários de drogas. A gente fazia patrulhamento direcionado pelo centro quando lhe encontramos pela Presidente Vargas, entramos pela Iracema de Carvalho Noronha, Venturosa Arcádia da Rocha, seguimos por várias ruas pelo Alto do Mirante, sendo ele abordado somente no final da Alziro Baltazar. Sim, devido a ele estar de moto, tinha certa vantagem, não respeitava placas de sinalização, passavam entre os veículos e a gente, o quanto pode, foi acompanhando. Estavam na mão dele e, com a mão esquerda, ele soltou as nove porções de crack. Sim. Eu sempre soube o endereço, pode ter sido um equívoco do delegado ao escrever, não sei, mas eu sabia o endereço a todo momento".

Felipe Bezerra da Rocha (informante do juízo): "Sim, a gente é amigo já tem cinco anos já. Como pessoa? É um menino esforçado, trabalha, faz uns bicos comigo de pintor, porque quando estou apertado, eu o chamo para trabalhar comigo. Sim, a mulher dele está grávida para ganhar neném. Não, nunca teve nada (a respeito de tráfico). De maconha só, porque eu e ele fumamos juntos: fazemos rateio, cada um dá metade e a gente fuma juntos. Não, nunca".

Interrogado, o acusado João Victor Santos De Oliveira negou a prática delitiva, dizendo que "No dia, eu sai do Ecoville, na minha casa, onde moro em condomínio fechado, sai para comprar maconha, porque sempre trabalhei fazendo entregas na parte da noite. Nesse dia, peguei a maconha, estava indo empinar minha moto, que é o que gosto de fazer, os policiais me viram na Alziro Baltazar, jogaram a viatura em cima de mim, em alta velocidade, eu - assustado - dei sentido na fuga, entrei na rua de terra, não tinha como dispensar nada ali, a maconha estava na minha pochete, saí da rua, dei sentido na Alziro Baltazar e bati minha moto. Eles me perguntaram onde eu morava, eu dei meu endereço, me disseram que me levariam até lá, mas me levaram para outra rua. Não ficaram nem dois minutos lá, disseram que me levariam até minha casa, mas me levaram à delegacia, onde fiquei a todo tempo sem saber de nada. Como estava machucado, me levaram em seguida ao pronto-socorro, como estava muito cheio, me levaram de volta à delegacia, quando soube do crack. A maconha era, realmente, minha, tem bastante tempo que fumo. O crack, por sua vez, não era meu, nunca nem vi isso, nunca mexi com isso, eu trabalho. Na Alziro Baltazar, assim que jogaram a viatura em cima de mim, eu pratico empinar a moto, me viram empinando e começaram a me seguir, eu só vi quando jogaram a viatura para cima de mim, subi só a Alziro Baltazar, entrei na rua de terra, andei três quadras e já voltei para a Alziro Baltazar. O dinheiro era do meu serviço, faço entrega na parte da noite e faço bicos de pintor. Na época, só trabalhava com entrega. Não, a Iracema de Carvalho Noronha fica bastante distante de onde estávamos. Não, não me lembro da senha do aparelho celular, já faz tempo".

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado se encontra em dissonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas policiais militares que empreenderam as investigações e efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em

detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Com relação aos relatos do informante, verifico que pouco contribuíram para o esclarecimento dos fatos, notadamente porque não presenciou a diligência, especialmente com relação ao momento da abordagem.

Outrossim, por possuir proximidade com o réu, seus relatos devem ser analisados com parcimônia, até porque, impossível averiguar a necessária imparcialidade para o depoimento.

No mais, frise-se que, na divergência existente entre os depoimentos das testemunhas, deve se dar preferência para o depoimento daquelas que não têm relação de parentesco com o réu, porquanto isentas.

Nessa toada:

"PROVA - Testemunhos conflitantes - Prevalência daqueles oferecidos por pessoas estranhas aos partícipes da cena criminosa - Condenação mantida.126 - No conflito de versões oferecidas por pessoas desinteressadas quanto à sorte da demanda, estranhas aos envolvidos na infração e por pessoas sentimental e afetivamente ligadas a um dos personagens, claro que as declarações das primeiras se haverá de conferir credibilidade maior." (RJDTACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 138 RELATOR:- CANGUÇU DE ALMEIDA).

Ressalto que, conforme relatado pelo Expert no laudo de fls. 258-273, o aparelho celular apreendido apresentou bloqueio por senha, não sendo possível obter os dados da memória (como aplicativos de troca de mensagens, por exemplo), de modo que não é possível tirar qualquer conclusão acerca desta prova.

Friso, no entanto, o supramencionado laudo não é prova essencial para a condenação do acusado, pois apenas corroboraria o quanto alegado e já comprovado por todas as demais provas coligidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, como se verá a seguir, as provas não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito pelo acusado.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade.

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado.

As testemunhas de acusação descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos, relatando inclusive que não foram até a residência do acusado porque este não autorizou o ingresso.

Assim, seria assimilar um enredo quicá fantasioso concluir que policiais militares que apenas por implicância atribuíam ao acusado a posse de considerável quantidade de entorpecentes.

A presunção iuris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos,

tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Nessa toada:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal . O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Tratando-se de versão escusatória, cabia ao réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito nestes autos. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a variedade de entorpecentes apreendidas em poder do acusado (crack e maconha); a relevante quantidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes (09 porções de "crack", embalados individualmente e prontos para o comércio pesando, aproximadamente 1,3 grama, além de uma porção de Cannabis sativa L.); a questionável a origem financeira dos valores apreendidos (R\$ 300,00, em notas trocadas), eis que nenhuma prova idônea foi trazida aos autos para comprovar sua licitude; o local onde se deram os fatos (várias denúncias anônimas realizadas durante o período de 20 dias que antecedeu a abordagem davam conta de que João Victor praticava o tráfico ilícito de entorpecentes através de "disque entrega" utilizando-se de uma moto vermelha); e a tentativa de ocultação do entorpecente (o acusado foi avistado conduzindo a motocicleta Honda/CG 160 Start, de cor vermelha e placas CPN0C78 e, na sequência, ao perceber a presença da viatura, dispensou parte dos entorpecentes na via pública) revelam que não se tratava de simples porte para consumo pessoal, mas sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros. E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias são favoráveis. Isso porque deixo de considerar, nesta fase de dosimetria, a fim de evitar "bis in idem", os critérios constantes do artigo 42, da Lei de 11.343/06, uma vez que tais circunstâncias serão consideradas na terceira fase de dosimetria.

Nesse sentido:

"[...] a Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, ainda, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza, o bis in idem. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder de discricionariedade, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente à quantidade e à

natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis in idem" (STF – HC: 121853 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: Dje-213 DIVULG 29-10-2014).

Destarte, considerando que não ostenta o réu maus antecedentes criminais e que todos os demais elementos são inerentes ao tipo penal, fixo as penas no patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não vislumbro presente nenhuma circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase de cálculo penal, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa. No entanto, verifico que o acusado foi flagrado trazendo consigo substância altamente letal ao ser humano, qual seja, crack, o que impõe a redução no patamar de 1/3, totalizando 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, excepcionalmente, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade, conduta social, personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação; e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a ser corrigida monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Insta consignar, nesse momento, a inconstitucionalidade da vedação à substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos prevista na Lei de Tóxicos.

Nessa toada:

"PENA – REGIME FECHADO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: Habeas Corpus nº 111.840, da relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: Habeas Corpus nº 97.256, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo

Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA - EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos - artigos 33 e 44 do Código Penal." (HC 123.329, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 07.06.2016).

DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o réu JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário-mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas; e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade; e prestação pecuniária em favor de instituição pública ou privada de destinação social no montante de um salário-mínimo, a ser corrigido monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Observando-se o artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sobretudo pela quantidade de reprimenda corporal aplicada e porque ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Concedo ao sentenciado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita.

Considerando que foram apreendidos nos autos R\$ 300,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 20), nos moldes do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 63, § 1º, da lei 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento dos valores (depósito judicial às fls. 77) em favor da União e o seu encaminhamento ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em virtude dos fundamentos utilizados nesta sentença.

Considerando que foi apreendido nos autos um aparelho celular (auto de exibição e apreensão de fls. 20) e que não há provas de sua efetiva utilização para a prática do delito, autorizo, após o trânsito em julgado, a restituição do aparelho celular ao sentenciado ou à pessoa por ele indicada, mediante pedido expresso. Nos termos do artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal, se não houver requerimento no prazo de 90 dias, a contar do trânsito em julgado, fica, desde já, declarado o seu perdimento e autorizado o leilão, a destruição do bem, ou ainda o recolhimento ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação (artigo 516 das NSCGJ), mediante comunicação ao SENAD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Autorizo a incineração da substância entorpecente remanescente, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários,

devendo ser instruída com os documentos pertinentes.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.
Publique-se.

de Presidente Epitácio, 22 de novembro de 2022

MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MAGISTRADO(A), NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.